

1500204-18.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-18.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048502/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23127236 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2048502 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELSON DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ELSON DE ARAÚJO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 19 de janeiro de

2022, na rua Catanduva, 274 - Matadouro, nesta cidade e Comarca, nas imediações de um entidade religiosa, trazia consigo, para venda, fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 29 porções de maconha e 47 porções de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar a fls. 147/148. Recebida a denúncia aos 24 de março de 2022 (fl. 151), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 174).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia e de seu aditamento, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 174).

A defesa pugnou pela desclassificação do crime para o previsto no artigo 28, da lei de drogas (fl. 174).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está plenamente comprovada. Os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 122/127) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são maconha e cocaína, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou, não obstante as escusas inconvincentes do acusado que em seu interrogatório judicial negou a prática da infração.

Elson declarou que apenas tinha em seu poder 14 papелotes de cocaína, destinadas ao seu consumo pessoal. Argumentou que quando os policiais chegaram e o abordaram, havia acabado de comprar a droga com o motorista de um veículo.

Imaginária a justificativa apresentada pelo acusado no sentido de que teria comprado as drogas de uma pessoa que transitava com um veículo na via pública, quando na verdade o comum é que usuários de drogas conduzam seus veículos em pontos de drogas visando adquirir-las de "traficantes" que estão ali parados. É falaciosa por demais tal alegação.

A par disto, ele sequer justificou a existência do restante da droga apreendida durante a diligência policial, em que pese não haver dúvidas sobre a apreensão do entorpecente pelos policiais. Não é crível que policiais inventem fatos ou "enxertem" a droga em desfavor de acusados, em especial quando sequer vestígio a respeito existe nos autos.

Por outro lado, o acusado não comprovou o exercício de atividade laboral, apenas argumentando que trabalhava como pintor de automóveis. Sequer soube indicar com o segurança o lugar onde poderia exercer sua profissão.

Ao final, declarou que teria adquirido a droga apreendida pelo valor de R\$ 100,00, uma vez que naquele dia havia recebido quantia aproximada em seu trabalho.

Ora, não é plausível que uma pessoa possa dispor de todo o dinheiro para aquisição de tamanha quantidade de entorpecente visando seu consumo pessoal, sem que seu sustento fosse comprometido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos dos guardas municipais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno traficante, não se pode

cogitar da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da fixação de regime inicial diverso do fechado. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, porém, sem repercussão na pena final. (TJSP; Apelação 0002855-33.2017.8.26.0526; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. Absolvição por falta de provas para o crime de tráfico - inocorrência - materialidade e autoria delitivas comprovadas - apreensão de variedade e expressiva quantidade de drogas na residência do recorrente, bem como a arma de fogo - circunstâncias da prisão do recorrente que atestam a prática de tráfico. Penas aplicadas de forma motivada, dentro dos parâmetros legais. Regime fechado é o correto diante da gravidade concreta dos crimes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0001123-48.2017.8.26.0548; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

No mais, ele se escusou da imputação por meio de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais querer lhe imputar injustificadamente crime de tamanha gravidade.

Se não bastasse a força de convencimento nesses elementos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

OPM Marcelo narrou que no dia dos fatos realizava patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas quando se deparou com o acusado em típica atividade de venda de drogas, uma vez que presenciou o momento em que ele entregava algo para o condutor de um veículo VW Gol. Declarou que quando o condutor daquele veículo notou a viatura policial, empreendeu fuga. Contudo, o acusado que se encontrava do lado de fora do automóvel foi abordado e revistado.

Acrescentou que durante a diligência, apreendeu 20 papелotes de cocaína, que estavam escondidos dentro da boca do acusado, além de 27 papелotes de cocaína e 20 buchas de maconha, encontrados em suas vestes, bem como a quantia de R\$ 20,00, em dinheiro. Indagado quanto às drogas, o acusado lhe admitiu que estava no local realizando a venda.

Suas palavras são ratificadas pelo PM Bruno, que em seu depoimento narrou a diligência realizada em conhecido ponto de tráfico de drogas e certificou o encontro de entorpecente em poder do agente, a par de sua admissão quanto à prática da infração.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar ficasubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos

carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frisa-se também que os agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local e a abordagem do agente, assim como sua revista e localização da droga, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de

drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, em porções prontas para a venda, a variedade de espécies, o local e as circunstâncias como foi encontrado, em plena atitude de comercialização, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de coloca-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afim, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente à figura "trazer consigo", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico. Inadmissível o pedido de desclassificação do delito imputado quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa e não da acusação o ônus da prova cabal e irrefutável da

alegação de ser usuário e dependente, mesmo porque a condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário de droga.

Sobre a matéria:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para a entrega e consumo de terceiros, drogas, consistentes em 21 (vinte e uma) porções de "Cannabis Sativa L.", popularmente conhecida como maconha e possuía e mantinha sob sua guarda 12 (doze) munições, calibre 22, uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. (TJ-SP - APL: 00008425720168260474 SP 0000842-57.2016.8.26.0474, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019).

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio, ou, subsidiariamente, afastamento da reincidência, mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional para o início de cumprimento de pena e detração penal. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado colocar algo em sua boca em atitude suspeita, justificando sua abordagem. Realizada busca pessoal, Renan cuspiu do interior de sua boca oito pedras de crack envoltas em papel alumínio. Ato contínuo, dando continuidade à busca, os milicianos encontraram em poder do acusado, mais especificamente no interior de suas vestes íntimas, trinta e quatro porções de maconha, todas acondicionadas separadamente em sacos plásticos. Ainda, no interior dos bolsos da bermuda que o denunciado vestia, os policiais apreenderam um celular Motorola e a quantia de R\$ 68,00 em espécie. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 2. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. B) Acusado reincidente específico que justifica o aumento adequado e proporcional aplicado pelo duto sentenciante, na segunda etapa da dosimetria da pena. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Acusado reincidente, sendo suficiente a reincidência para a negativa da diminuição. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício. 3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente - Artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, § 3º, do Código Penal. 4. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável a detração, para tanto, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, b, LEP). Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00005459420188260566 SP 0000545-94.2018.8.26.0566, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes criminais recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 75/80. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda etapa, certificada a reincidência do agente a fls. 81, não utilizada para efeitos de maus antecedentes, suas penas serão elevadas em 1/6, não havendo outras atenuantes ou agravantes a considerar ($6 \text{ anos} + 1/6 = 7 \text{ anos}/600 \text{ dias} + 1/6 = 700 \text{ dias-multa}$).

Na etapa derradeira, não deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III.

O laudo anexo (fls. 133/136) apontou que o lugar do crime dista cerca de 130 metros da igreja mais próxima. A lei não especificou distância para aplicação da majorante, trazendo expressão que depende de interpretação, qual seja, nas imediações de....

A distância referida não pode ser considerada compatível com o termo imediações, que tem significado de redondezas, arredores, vizinhanças ou proximidades. Isto porque se exige uma caminhada para alcançar tal distância, além de estar comprometido o contato visual de qualquer pessoa normal, na maioria dos casos, como na espécie.

A par disto, a prova dos autos não demonstrou uma efetiva influência do tráfico exercido pelo agente neste local.

Logo, a proteção legal visando coibir o tráfico próximo à instituição em debate não deve operar na espécie.

O acusado é reincidente, razão pela qual não se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação do da prática delitiva, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Por conta dos mesmos fundamentos o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ELSON DE ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Recomende-se na prisão onde ele estiver.

Concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 08 de junho de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA